

《【문제9.6】

<사례>

행정청 A는 甲이 운영하는 공장에 대하여 `토양환경보전법` 위반을 사유로 사용중지 명령을 내렸다. 甲은 해당 처분이 처분 권한이 없는 자에 의해 행해진 것으로서 중대하고 명백한 하자가 있어 당연무효라고 주장하며 무효확인소송을 제기하였다. 소송 계속 중 甲은 공장 가동이 중단될 경우 거래처와의 계약 위반으로 인해 회복하기 어려운 막대한 손해가 발생할 것을 우려하여, 판결 확정 시까지 처분의 효력을 멈춰달라는 가구제 수단을 강구하고 있다. 한편, 인근 주민 乙은 행정청 A가 甲에게 내린 사용중지 명령에 대하여 무효확인소송을 제기하면서, 행정청 A가 향후 해당 부지에 대하여 내릴지도 모를 다른 완화된 처분을 미리 금지해달라는 가처분을 신청하고자 한다.

(물음1) 무효확인소송에서 행정소송법 제23조의 `집행정지` 규정이 준용되는지 여부를 밝히고, 무효확인소송에서의 집행정지 요건 중 `회복하기 어려운 손해`의 의미에 대하여 취소소송과 비교하여 서술하라.》

<문제9.6의 물음1> 무효확인소송에서 집행정지 규정의 준용 여부와 회복하기 어려운 손해의 의미

I 문제의 제기

- 사안에서 행정청 A가 甲의 공장에 대하여 사용중지 명령을 하였고, 甲은 해당 처분의 무효확인소송을 제기하면서 처분의 효력을 정지시키기 위한 가구제 수단을 모색하는 상황이다. 쟁점으로 <무효확인소송에서도 취소소송과 마찬가지로 행정소송법상 집행정지 규정이 준용되는지 여부와 집행정지 요건인 회복하기 어려운 손해의 의미>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 무효확인소송에서의 집행정지 인정 여부와 회복하기 어려운 손해의 판단 기준을 취소소송과 비교하여 서술한다.

II 무효확인소송에서 집행정지의 준용 여부

1. 의의

- 집행정지는 처분의 집행이나 효력의 발생을 잠정적으로 멈추어 원고의 권리를 보호하는 가구제 수단이다. 무효확인소송은 처분의 효력이 존재하지 않음을 전제로 하지만, 외형상 처분이 존재하는 이상 그로 인한 집행을 위험을 차단할 필요가 있다.

2. 법적 근거 및 견해의 대립

(1) 긍정설 및 행정소송법의 태도

- 현행 "행정소송법 제38조 제1항"은 "제23조"를 명시적으로 준용하고 있다. 무효인 처분이라도 처분의 외형이 남아 있어 집행력이 행사될 가능성이 있으므로, 국민의 권리 보호를 위해 집행정지를 인정해야 한다는 취지이다.

(2) 부정설

- 무효인 처분은 처음부터 아무런 효력이 없으므로 정지할 효력 자체가 존재하지 않는다는 논리이다. 즉, 관념적으로 존재하지 않는 효력을 정지한다는 것은 논리적으로 모순이라는 견해이다.

(3) 판례의 입장

- "대법원"은 행정소송법의 준용 규정에 따라 무효확인소송에서도 집행정지가 허용된다는 점을 명확히 하고 있다. 다만, 무효확인소송에서의 집행정지는 취소소송과 비교하여 그 요건인 손해의 성격에 대하여 다소 엄격하게 해석될 여지가 있다.

III 집행정지 요건 중 회복하기 어려운 손해의 의미

1. 취소소송에서의 의미

(1) 개념의 확장

- 과거에는 금전 보상이 불가능한 손해만을 의미했으나, 현대적 "판례"는 금전 보상이 가능하더라도 사회통념상 원고가 참고 견디기 어렵거나 원상회복이 현저히 곤란한 경우를 포함하는 광의의 개념으로 해석한다.

(2) 구체적 판단 기준

- 사업의 중단으로 인한 막대한 경제적 손실, 기업 이미지의 실추, 파산의 위기 등 원고의 법적 지위에 심대한 타격을 줄 우려가 있는 경우 회복하기 어려운 손해로 인정된다.

2. 무효확인소송에서의 의미 및 비교

(1) 논리적 차이

- 무효인 처분은 처분 그 자체로 효력이 없으므로, 원고는 처분을 무시하고 행동할 수도 있다. 그러나 사실상의 강제집행이 예정되어 있거나 외형상 처분으로 인해 법률관계가 극도로 불안정해지는 경우 가구제의 필요성이 발생한다.

(2) 판례의 독특한 입장

- "대법원"은 무효확인청구의 소에는 처분의 효력 정지를 구할 법률상 이익이 있어야 한다고 판시하면서, 만약 처분의 효력을 정지하지 않더라도 처분이 당연무효임을 주장하여 민사소송 등 다른 방법으로 손해를 충분히 구제받을 수 있다면 집행정지의 필요성을 부정적으로 보는 경향이 있다.

(3) 비교 요약

- 취소소송에서는 처분의 공정력 때문에 일단 따라야 하는 의무가 발생하므로 손해의 범위를 넓게 보지만, 무효확인소송에서는 처분에 공정력이 없으므로 오직 실행력이 행사되어 실제로 권리가 침해될 긴급한 사정이 있는 경우에 한하여 보다 엄격하게 해석되는 측면이 있다.

IV 사안의 적용

1. 집행정지의 준용 및 신청

- 사안에서 행정청 A의 사용중지 명령은 무효확인소송의 대상이며, "행정소송법 제38조 제1항"에 따라 "제23조" 집행정지 규정이 준용된다. 따라서 甲은 공장 가동 중단이라는 위기에 대응하기 위해 집행정지를 신청할 수 있다.

2. 회복하기 어려운 손해의 존부

- 甲은 공장 가동 중단 시 거래처와의 계약 위반 및 막대한 손해 발생을 주장하고 있다. 이는 단순히 금전으로 보상될 수 있는 범위를 넘어 기업의 존립을 위협하거나 거래 질서를 파괴할 우려가 있는 경우에 해당한다. 비록 무효확인소송에서 손해의 요건을 비교적 엄격히 보더라도, 사용중지 명령이라는 직접적인 강제력이 수반되는 처분의 경우 회복하기 어려운 손해 및 긴급한 필요가 인정될 가능성이 높다.

V. 결론

- 무효확인소송에서도 행정소송법의 준용 규정에 따라 집행정지 제도가 인정된다. 이는 처분의 무효 여부와 상관없이 사실상의 집행력을 차단하여 국민을 보호하기 위함이다. 집행정지의 요건인 회복하기 어려운 손해는 취소소송과 마찬가지로 원상회복이나 금전 보상이 극도로 곤란한 경우를 의미하나, 무효인 처분은 원칙적으로 효력이 없다는 특수성 때문에 실제 집행 가능성이 구체적으로 증명되어야 한다는 점이 취소소송과의 실무적 차이점이다. 사안의 甲은 공장 중단으로 인한 파괴적 손해를 소명함으로써 가구제를 받을 수 있을 것으로 판단된다. 이러한 법리는 무효인 행정행위의 외형이 가져오는 법적 혼란을 잠정적으로 해소하고, 본안 판결 전까지 신청인의 권익을 실효적으로 보전하는 데 기여한다.